

1501550-34.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501550-34.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501550-34.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2122575/2021 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 17738820 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 76/21/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2122575 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2122575/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jackeline Barreto da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JACKELINE BARRETO DA SILVA e RAFAELLA DE MORAES, qualificadas nos autos, estão sendo processadas como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, em 05 de maio de 2021, por volta das 15hs30min, na via pública da Avenida Canadá, bairro Parque Residencial Belinha Ometto, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, as acusadas, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, em atividade de tráfico ilícito, venderam, guardavam e tinham em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 84,5g, e 37 (trinta e sete) porções de

Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando cerca de 58,59g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID 19, as rés, agindo em concurso, venderam, guardavam e tinham em depósito drogas para fins de comercialização.

Ocorre que policiais civis realizavam diligências no sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram as acusadas efetivando venda de entorpecentes para usuários que por ali passavam.

Durante o acompanhamento, foi visualizado, ainda, o local onde as drogas eram ocultas. Realizada a abordagem, com RAFAELLA foi encontrada a quantia de R\$122,00 (cento e vinte e dois reais), obtida com o narcotráfico.

Em seguida, realizada vistoria nos locais onde JACKELINE e RAFAELLA foram vistas anteriormente, os agentes públicos localizaram 41 porções de cocaína e 37 de maconha, drogas que ali guardavam e tinham em depósito também para serem entregues ao consumo de terceiros.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação das rés para que apresentassem defesas preliminares, que vieram aos autos (fls. 156/157 e 174).

A denúncia foi recebida em 02 de julho de 2021 (fls. 180/181).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e as rés, interrogadas ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram.

Memoriais orais do Ministério Público (mídia) e alegações finais escritas da Defensoria Pública (fls. 293/325).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, aprecio as preliminares levantadas pela Defesa.

O artigo 212 do Código de Processo Penal apenas afastou o sistema presidencialista de audiências em que somente o juiz podia formular perguntas à vítima, testemunha e réu, permitindo que a parte formule diretamente os questionamentos.

Todavia, é importante salientar que não houve qualquer alteração no tocante aos poderes instrutórios do juiz, consoante quis fazer crer a Defesa. De todo modo, ainda que se adote posicionamento diverso, verifica-se que não houve qualquer insurgência, por parte da Defesa, durante a audiência, operando-se, quanto a esta questão, a preclusão, já que alegada apenas em sede de memoriais escritos.

E há que ser demonstrado prejuízo para o acolhimento da nulidade apontada, que evidentemente não aconteceu, na medida em que foi dada ampla possibilidade das partes formularem diretamente todas as suas perguntas e de, assim, influírem no ânimo do julgador, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, confira-se:

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receitação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP.

3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido". (STF, RHC 111414, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012).

"RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 - NULIDADE MERAMENTE RELATIVA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (STF, RHC 111251 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II - Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que "o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III - O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV - Ordem denegada." (STF, HC 117102, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013).

"Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico de entorpecentes e Corrupção Ativa. Alegada inversão na ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Nulidade do processo. Inocorrência. Ausência de comprovação de prejuízo. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "a inobservância da ordem de inquirição de testemunhas não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o ato processual ou a ação penal, razão por que a demonstração do efetivo prejuízo se faz necessária para a invalidação do ato" (HC 114.787, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que a nulidade foi arguida apenas em sede de apelação e não houve a devida demonstração de eventual prejuízo suportado pela acusada. Incidência da Súmula 523/STF ("No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"). 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual." (STF, HC 114789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Pelo que se tem nos autos, não foi vedado à defesa nem à acusação inquirir diretamente as testemunhas. O juiz de primeira instância apenas afirmou, com base na sua interpretação do art. 212 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 11.690/2008, que deveria inquirir primeiramente as testemunhas. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Recurso ao

qual se nega provimento".(STF, RHC 113382, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 05-10-2012 PUBLIC 08-10-2012).

Também não há que se falar em prova ilícita em razão da não realização do "Aviso de Miranda" quando da prisão em flagrante. Ora, não há, no direito brasileiro, qualquer regra explícita sobre o chamado "Aviso de Miranda" (advertência de Miranda ou "Miranda rights"), originado do direito norte-americano, do julgamento Miranda versus Arizona, da Suprema Corte Americana (384 U.S 436, de 1966).

O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal dispõe que "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". Ademais, não serão consideradas lícitas as provas obtidas a partir de declarações de quem for preso sem a prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio (CPP, artigo 157).

Entretanto, para fins de caracterização da violação do direito ao silêncio e a não autoincriminação, é necessário a existência de interrogatório "forçado", em que o custodiado é obrigado a falar, com a existência de um ambiente de intimidação, o que diminuiu o direito a não se incriminar.

No caso em tela, não foi isso o que se verificou. Para o reconhecimento da nulidade por conta da falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio, há a necessidade da demonstração de prejuízo concreto, o que não é o caso em discussão, já que a conduta ilícita das acusadas pode ser extraída de outros elementos de prova, como a oral, pericial e documental.

Tal conclusão não destoa da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

DESCCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL

FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA.

MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. (...) 3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto

ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada (...) (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

A preliminar de prova ilícita em razão da ilegalidade da busca pessoal será analisada em conjunto com o mérito da ação penal.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, no mérito o pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 27/29), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), laudo pericial com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 37/40 e 119/121)

e imagens de fls. 64 (mídia), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a Autoridade Policial, a acusada JACKELINE permaneceu silente, no exercício de seu direito constitucional (fls. 10).

Em Juízo, a acusada JACKELINE disse que tem 21 anos. Trabalha no lanche como chapeira. É solteira. Nunca foi processada criminalmente. Não teve passagem na infância. Não quis responder as perguntas de mérito por orientação do Defensor Público (mídia).

Perante a Autoridade Policial, a acusada RAFAELLA permaneceu silente, no exercício de seu direito constitucional (fls. 09).

Em Juízo, a ré RAFAELLA disse que tem 25 anos. Trabalhava como mototaxista, com entregas. É solteira. Já foi processada criminalmente uma vez por tráfico. Os fatos são verdadeiros. Fez tudo isso por causa do dinheiro. Está arrependida. Tinha dinheiro em seu poder. Jackeline não teve qualquer participação no tráfico. Não viu as filmagens. Jackeline chegou a falar com ela naquele dia, a colega sabia que ela vendia drogas. Quem fornecia drogas é um cara de outro bairro. Deixou os entorpecentes em um galpão. As drogas foram deixadas lá embaixo. Não conhecia os policiais. Ficou calada na Delegacia. Está confessando porque é o melhor a ser feito. Confessa que estava vendendo drogas (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, a qual incrimina ambas as acusadas e reforça a confissão parcial de RAFAELLA.

O policial civil Rafael Silva Varuzza disse que houve determinação da autoridade policial para irem nas biqueiras. Estavam em duas equipes policiais. Os colegas Tiago e Ricardo teriam que captar imagens, enquanto Anderson e ele iriam fazer a abordagem das pessoas envolvidas. Foi então que Tiago fez contato noticiando ter visto a venda de entorpecentes praticada por duas moças, com características masculinas. A fotografia delas durante a ação foi repassada e o local de retirada das drogas foi indicado. Foram até o local e abordaram as duas acusadas. Indagada, RAFAELLA disse que tinha dinheiro em seu poder. Tiago e Ricardo foram ao local de onde eram retiradas as drogas e lá encontraram pinos de cocaína e porções de maconha. Deram voz de prisão. Posteriormente, no trajeto, RAFAELLA e JACKELINE confessaram a traficância. Não conhecia as acusadas. Só foi o responsável pela abordagem. As características delas foram repassadas pelo colega Tiago. Em poder das acusadas não havia drogas, mas no local de onde era retirado foram encontrados entorpecentes. Tiago e Ricardo falaram de onde eram retiradas as drogas e naquele local seus colegas encontraram entorpecentes. O local dos fatos é um portão e tem um relógio de força, tinha que pular o portão para obter as drogas. Acredita que houve filmagem. Ficou com as acusadas e Anderson permaneceu na esquina debaixo (mídia).

O policial civil Tiago Andrade Pucci disse que, no dia dos fatos, por determinação do Delegado, foram fazer diligências no bairro Belinha Ometto para filmar biqueiras ali existentes. Ricardo e ele estavam numa viatura descaracterizada. Viram as duas acusadas no meio da avenida. Esperaram um pouco e viram ambas fazendo venda de entorpecentes, havendo filmagens. A que tinha estatura menor (JACKELINE) pulava o muro, pegava drogas e passava para a outra menina (RAFAELLA). Passaram a ocorrência para outra equipe fazer abordagem. As meninas foram abordadas e com uma delas havia dinheiro. Ricardo e ele saíram do local e foram até onde eram retiradas as drogas, onde o muro era pulado. Pulou o portão e encontrou maconha e cocaína. Avisaram a outra equipe. Deram voz de prisão. Identificou em audiência quem pulava o muro. Indagadas, ambas as acusadas negaram. No caminho da Delegacia RAFAELLA e JACKELINE

assumiram o crime. Já havia visto uma delas naquele local, mas não deu certo de fazer abordagem. Com uma delas havia dinheiro. Era JACQUELINE quem buscava as drogas e passava para RAFAELLA. As acusadas estavam juntas na venda de drogas. Não abordou nenhuma das duas. RAFAELLA não pulava o muro, era JACKELINE quem pulava e buscava as drogas. Viu JACKELINE em audiência, era ela quem pulava o muro, as acusadas atuavam em conjunto no comércio. Houve filmagem da ação policial. RAFAELLA era mais gordinha e não conseguia pular o local, o entorpecente estava escondido no local onde JACKELINE pulava (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais civis, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

De acordo com a prova oral colhida, policiais civis faziam diligências no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, com viatura descaracterizada, quando visualizaram as rés na prática ilegal da venda de entorpecentes, havendo filmagem da ação juntada aos autos (mídia – fls. 64) indicando a atuação conjunta das acusadas e o local de armazenamento das drogas.

Para tanto, JACKELINE pulava o portão e pegava os entorpecentes daquele local por ser a pessoa mais magra, entregando-os para a parceira RAFAELLA, que foi filmada vendendo as porções de drogas para um motociclista. Ambas as acusadas foram reconhecidas em audiência pelos policiais civis como sendo as autoras do delito, havendo unidade de desígnios na traficância.

Na abordagem, com a acusada RAFAELLA foi localizada a quantia de R\$122,00 (cento e vinte e dois reais) e, no local onde as acusadas ocultavam os entorpecentes e que JACKELINE pulava, os agentes policiais localizaram 41 porções de cocaína e 37 de maconha, prontas para a venda ilícita.

Embora RAFAELLA tente isentar JACKELINE de qualquer envolvimento com o tráfico, sua versão contraria o testemunho dos policiais civis em audiência e não encontra amparo em qualquer prova produzida, sendo isolada a sua versão nessa parte.

Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha, embaladas de maneira individualizada), as circunstâncias da prisão, o encontro do valor em dinheiro e o local da abordagem, com depoimento incriminador dos agentes públicos e confissão parcial de RAFAELLA, tudo a apontar as rés como sendo pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos policiais civis para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa que corroborassem a versão da imputada JACKELINE de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais civis que efetuaram a abordagem e prenderam ambas as acusadas em flagrante delito.

É inquestionável que a ação da polícia civil se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante diligências em local conhecido pela traficância ilícita, policiais civis filmaram as acusadas agindo em conjunto na prática do tráfico de drogas, na medida em que venderam para usuários, guardaram e tinham em depósito 41 porções de cocaína e 37 de maconha, havendo encontro de dinheiro produto do comércio, fato confessado em parte pela acusada RAFAELLA, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...) 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consume.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes

preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Por outro lado, não é caso de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal. Não há provas de que as acusadas tenham agido para se aproveitar da situação de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19. O crime foi cometido em circunstâncias normais, motivo pelo qual afasto o reconhecimento da agravante.

A respeito do assunto, cito os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência da agravante em questão:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"Na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime

em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. Ademais, como bem destacou o parecer ministerial às fls. 73, grifei "A despeito da maior censurabilidade da conduta praticada no período de calamidade pública, o referido evento, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, sob pena de responsabilização objetiva do agente." Por essas razões, entendo que deve ser afastada a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal(...)" (STJ, HC 632.019/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 10/02/2021).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra as acusadas, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

JACKELINE BARRETO DA SILVA

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis à acusada, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não é caso de reconhecimento de agravantes e atenuantes. A pena já foi fixada no mínimo legal, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ, razão pela qual não será considerada a atenuante de menoridade relativa.

Na terceira fase, sendo a ré primária, de bons antecedentes, não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

Ausentes quaisquer causas de aumento quanto à acusada.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno a pena acima definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (apreensão de 41 porções de cocaína, pesando aproximadamente 84,5g, e 37 porções de maconha, pesando cerca de 58,59g).

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

RAFAELLA DE MORAES

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis à ré, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A ré é reincidente específica (conf. F.A. de fls. 49/52, proc. nº 0021732-57.2017.8.26.0320). Todavia, ela confessou parcialmente os fatos. Desta forma, elevo a pena em 1/6 (e não 1/5), operando a compensação parcial, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação como no caso em tela (cf. STJ, AgRg no HC 625.076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; HC 208.590/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 19/10/2015; HC 251.532/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já

decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que a acusada é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, considerando inclusive o posicionamento do Supremo Tribunal Federal firmado no acórdão proferido no HC n.º 118.553/MS. Anote-se que a ré RAFAELLA é reincidente.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei n.º

11.343/2006.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JACKELINE BARRETO DA SILVA, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incursa no art. 33, caput, c/c a redução prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; e RAFAELLA DE MORAES, qualificada nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, como incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima fundamentados, em favor da acusada JACKELINE.

A corré RAFAELLA não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu presa durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de, solta, voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendada na prisão em que se encontra recolhida, anotando-se que é reincidente específica.

A ré JACKELINE, por sua vez, poderá apelar em liberdade, condição na qual respondeu ao processo.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária das acusadas e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido. Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, os nomes das rés deverão ser lançados no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA